

1013124-34.2022.8.26.0011

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Vanessa Bannitz Baccala da Rocha

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XI - Pinheiros

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... despesas até o momento da comunicação formal do roubo, furto, perda, extravio ou fraude - Inteligência do art. 51, IV, do CDC - Inexigibilidade do débito e cancelamento da negativação indevida" (0002808-92.2007.8.26.0111 Apelação; Relator: Marino Neto; Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/08/2015).

De rigor, portanto, a declaração de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XI - Pinheiros

4ª Vara Cível

Rua Jericó s/n, São Paulo - SP - cep 05435-040

1013124-34.2022.8.26.0011 - lauda

SENTENÇA

C O N C L U S ã O

Em 30 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz Dr. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha Eu, _____, Elaine Aparecida Silva Andrade de Queiroz, escr., subs..

Processo nº:

1013124-34.2022.8.26.0011 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Regina Maria Barbosa Di Ninno

Requerido:

Itaú Unibanco S.A.

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha

Vistos.

REGINA MARIA BARBOSA DI NINNO ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de em face de BANCO ITAU S/A, alegando, em síntese, que dia 15 de julho de 2022 recebeu ligação em sua residência, afirmando tratar-se de funcionário da empresa ré, sabendo do seu histórico de compras, dizendo que haviam sido feitas compras em seu cartão, pedindo a requerente que o entregasse para um motoboy da empresa, que passaria na casa da autora para buscar. Desse modo, agiu conforme orientação e entregou o cartão. Posteriormente, verificou que se tratava de um golpe, sendo que ligou ao banco, que somente fez o bloqueio do cartão, mas ignorou o estorno das transações. Pontuou que o requerido chegou a realizar estorno parcial, entretanto não de todas as operações, resultando em prejuízo para autora, no valor de R\$7.400,80.

]

Requeru a concessão de tutela antecipada para determinar que o requerido seja impedido de debitar as parcelas nos cartões de crédito da Autora: Mastercard - n.º 5415.xxxx. xxxx.3321 -R\$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) parcelados em 10x e VISA - n.º 4590.xxxx. xxxx.1323 - R\$3.000,80 (três mil reais e oitenta centavos) parcelados em 10 vezes, sendo correto apontar que de ambos os cartões, a Autora já suportou o pagamento de 03 parcelas em cada, o que já totalizou um prejuízo de R\$1.140,00 no Mastercard e R\$900,24 no Visa, motivo pelo qual necessário se faz a concessão da liminar pleiteada; Ao final, requereu a procedência da ação, a devolução integral dos valores já suportados/pagos pela autora e condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais, no importe de R\$14.801,60, bem como em custas e honorários. Requeru gratuidade da justiça. Com a inicial vieram documentos.

A decisão de fls. 43/44 concedeu a medida liminar pleiteada. Às folhas 153/159 a autora recolheu as custas processuais.

Contestação do banco requerido às folhas 47/56. Preliminarmente, requereu a adequação do polo passivo para constar BANCO ITAUCARD S.A. Impugnou a gratuidade da justiça. Afirmou ter dado cumprimento à tutela. Pugnou pela improcedência da demanda. Sustentou ter agido com boa fé na solução do problema, sendo que não há como falar em inexigibilidade dos débitos, tendo em vista que banco regularizou a situação realizando o estorno dos valores reclamados. Entendeu serem inexistentes os danos morais e materiais, razão pela qual requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Houve réplica (fls. 162/169).

É o relatório.
Fundamento e decido.

De proêmio, regularize-se o polo passivo para que conste somente BANCO ITAUCARD S.A.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que as alegações feitas pelas partes e os documentos por elas apresentados permitem a prolação de sentença.

Observo que o juiz da causa é destinatário primordial da prova, que é produzida com o intuito de formar sua convicção sobre os fatos alegados pelas partes, sendo o julgamento antecipado faculdade do magistrado. Por esse motivo, reputo desnecessária a produção de demais provas, sendo os documentos juntados suficientes para apreciação da demanda.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes, de fato, rege-se pelas normas aplicáveis às relações de consumo, portanto, a demanda deverá submeter-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso, a ação é procedente em parte.

Constou da exordial que a autora possuía cartão de crédito da requerida e que dia 15 de julho de 2022, recebeu ligação em sua residência, afirmando tratar-se de funcionário da empresa ré, sabendo do seu histórico de compras, dizendo que haviam sido feitas compras em seu cartão, não reconhecidas, pedindo a requerente que o entregasse o cartão para um motoboy da empresa, que passaria na casa da autora para buscar. Desse modo, a autora agiu conforme orientação e entregou o cartão. Posteriormente, verificou que se tratava de um golpe, sendo que ligou ao banco, que somente fez o bloqueio do cartão, mas ignorou o estorno da totalidade das transações, de modo que a autora incorreu em prejuízo de R\$7.400,80.

Ao tomar conhecimento das operações indevidas, a autora requereu o bloqueio do cartão e solicitou o estorno da operação. Buscou a inexigibilidade do débito junto à instituição financeira, mas não obteve êxito, lavrando ainda Boletim de Ocorrência (fls.41/42).

Na contestação ofertada, a ré sustentou, em síntese, que agiu de boa-fé, efetuando o estorno das transações. Entretanto, tal providência somente foi tomada após a autora adentrar com a ação.

Cumprе ressaltar que autora e ré enquadram-se, respectivamente, nos conceitos estabelecidos pelos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, do mesmo Código, estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, por mostrarem-se excessivamente onerosas, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

A disseminação do uso de cartões magnéticos com chip, senhas e transações pela internet e/ou outros meios eletrônicos ocorreu não só para facilitar a vida do cliente, mas e, essencialmente, para atender à comodidade dos bancos e seus interesses econômicos, reduzindo os custos de sua própria atividade. Além disso, não há prova nos autos de que a autora tenha feito a entrega de sua senha aos fraudadores, o que permitiria que a compra fosse realizada pela internet, por exemplo, com os dados do cartão e o código de segurança localizado no verso do plástico.

No caso dos autos, seria claramente abusivo eximir a instituição financeira de responsabilidade no caso de fraudes. Ademais, além do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, in casu, a Teoria do Risco da Atividade, adotada pelo Código Civil.

De fato, por ser fornecedora de serviços, a responsabilidade da ré, no caso vertente, é objetiva, nos termos dos artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, e também pelo risco da atividade, previsto pelo parágrafo único do artigo 927 do Código Civil.

No presente caso não está presente nenhuma excludente da sua responsabilidade da instituição financeira. Para tanto, seria necessária prova de culpa exclusiva da vítima, inexistente nos autos. Com efeito, embora a autora possa ter sido ludibriada, a instituição financeira também contribuiu para a ocorrência, na medida em que a operação fraudulenta foi incompatível com aquelas que eram realizadas pela autora, devendo a requerida ter procedido ao bloqueio preventivo do cartão da requerente.

Ressalto que o banco não demonstrou a adoção de medidas de segurança a fim de evitar a transação contestada, posto que não houve o bloqueio preventivo, nem contato com a parte autora pela administradora do cartão, mesmo diante da alteração abrupta do perfil de compras.

A jurisprudência do E.TJSP já adotou entendimento de que a instituição financeira tem responsabilidade pelo evento criminoso, justamente porque as operações realizadas destoaram do padrão de uso do consumidor:

"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com pedido de indenização por danos materiais e morais Fraude bancária conhecida como "golpe do motoboy". Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. RESPONSABILIDADE CIVIL. Legitimidade passiva do banco que se confunde com o mérito. Relação negocial regida pelo CDC. Autora vítima de estelionato, após telefonema de terceiros detentores de seus dados pessoais sigilosos. Compras diversas a crédito e a débito em curto espaço de tempo que destoam do perfil de consumo da correntista, sem que o banco tenha procedido a bloqueio preventivo. Falha na prestação do serviço

configurada. Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responsabilidade, na forma da Súmula nº 479 do STJ. Indenização material bem fixada na origem. Recurso não provido." (TJSP; Apelação nº 1032085-89.2018.8.26.0002; Relator: Helio Faria; Órgão julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Data de publicação: 05/12/2018).

"FATO DO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE. COMUNICAÇÃO À FORNECEDORA. COMPRAS QUESTIONADAS. PERÍCIA. Fatos narrados suficientes. Desnecessidade de perícia. Dados sigilosos de conhecimento dos fraudadores, tais como cartão desbloqueado no exterior e conta conjunta. Fatos que já demonstram a desídia do fornecedor. FATO DO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE. COMUNICAÇÃO À FORNECEDORA. COMPRAS QUESTIONADAS. DANOS MATERIAIS. O autor confessou haver entregue o cartão de crédito e senha a criminoso, que se fez passar por motoboy enviado à sua casa pelo 'banco' para providências com relação a uma suposta clonagem. Compras em estabelecimentos que destoam da conduta e do parâmetro habitual da cliente. Obrigação do banco em perceber e evitar. Dados fornecidos pelos fraudadores ao consumidor que eram sigilosos e que tiveram acesso junto ao sistema da instituição financeira. Responsabilidade objetiva. Questão pacificada nesta Turma. Recurso improvido" (0006862-95.2016.8.26.0011 Recurso Inominado; Relator: Rodrigo de Castro Carvalho; Órgão julgador: 3ª Turma Recursal Cível Data do julgamento: 26/06/2017)

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória cumulada com reparação de danos materiais e morais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Compras e saques indevidos realizados por terceiro com cartão de crédito do correntista. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras - Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova - Falha de segurança interna do banco, que não identificou e nem bloqueou o cartão diante de consumo fora do padrão. Prestação de serviços deficitária. Responsabilidade objetiva da instituição nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça Sentença de parcial procedência. Manutenção. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido." (TJSP; Apelação nº 1006883-50.2017.8.26.0001; Relator: Daniela Menegatti Milano; Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Data de publicação: 05/12/2018).

Vale observar, ademais, que a jurisprudência também já consolidou entendimento segundo o qual é manifesta a "nulidade da cláusula contratual que impõe ao consumidor a responsabilidade absoluta pelas despesas até o momento da comunicação formal do roubo, furto, perda, extravio ou fraude - Inteligência do art. 51, IV, do CDC - Inexigibilidade do débito e cancelamento da negativação indevida" (0002808-92.2007.8.26.0111 Apelação; Relator: Marino Neto; Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/08/2015).

De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade da operação fraudulenta.

De outra sorte, não vislumbro a ocorrência dos alegados danos morais. A despeito do aborrecimento causado pelo débito indevido em fatura de cartão de crédito, o fato não supera o dissabor próprio a relações negociais que não se desenvolvem a bom termo, ausente qualquer relato na inicial de fato específico capaz de produzir abalo psíquico e emocional que justificasse a percepção de violação aos direitos da personalidade.

Embora desagradáveis, os fatos em análise não possuem a envergadura necessária para lesionar direito personalíssimo. No caso em tela, não há notícia de que tenham havido consequências graves. Destacando-se o fato de que a autora também contribuiu para a ocorrência, ainda que não tenha sido mediante culpa exclusiva, pois deixou de agir com a devida vigilância na guarda de seu cartão de crédito e de suas informações. De rigor, pois, o reconhecimento de que não houve dano moral passível de indenização, mesmo porque o nome do requerente sequer foi negativado.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Regina Maria Barbosa di Ninno em face de Banco Itaucard S/A, para a) confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida às fls. 43/44; b) declarar a nulidade das operações contestadas pela autora em seu cartão Mastercard - n.º 5415.xxxx. xxxx.3321 - R\$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) parcelados em 10x e VISA - n.º 4590.xxxx. xxxx.1323 - R\$3.000,80 (três mil reais e oitenta centavos) parcelados em 10 vezes, no período contestado pela autora, bem como eventuais encargos cobrados em virtude destas transações; c) determinar a restituição de valores ora declarados inexigíveis que ainda não foram ressarcidos à autora, compreendendo os já pagos, e determinar que a ré se abstenha de qualquer medida de cobrança em relação à operação discutida nestes autos, inclusive com a proibição de inclusão do nome do requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Em consequência, julgo extintos estes autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência recíproca: a) as partes arcarão, em igual proporção, com as despesas processuais (art. 86, CPC); e b) nos termos do artigo 85, §2º e 6º, do CPC, arcará a requerida com os honorários dos advogados da parte autora, fixados em 15% do valor da condenação (débito considerado inexigível), ao passo que arcará a requerente com os honorários dos advogados da parte ré, que fixo em 15% sobre a parte em que sucumbiu no pedido (valor postulado à título de indenização por danos morais).

P. I.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.